

1502321-12.2021.8.26.0320
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/01/2022
... Confira-se:

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Preliminares de nulidade - Ilegalidade da busca pessoal - Inocorrência - comportamento suspeito em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e tentativa de fuga ao perceber a aproximação da viatura policial - Circunstâncias a indicar a justa causa para a atuação policial - Posterior apreensão de drogas em poder do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
1ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502321-12.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502321-12.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2201001/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19244168 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 1736/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2201001 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1736/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2201001/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Eliei Rodrigo da Silva

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

ELIEL RODRIGO DA SILVA, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, em tese, no dia 26 de julho de 2021, por volta das 14h20min, na Rua Irineu Casemiro, nº 41, Parque Abílio Pedro, nessa cidade e comarca, trazia consigo, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 25 (vinte e cinco) porções de Erythroxyton coca, popularmente conhecida como "cocaína", e 55 (cinquenta e cinco) porções de Erythroxyton coca, popularmente conhecida como "cocaína", na forma de "crack".

Defesa preliminar à fl. 111.

A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2021 (fl. 159).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 170/175). A Defensoria Pública, por seu turno, postulou, preliminarmente, a nulidade decorrente da irregularidade na formulação de perguntas às testemunhas, diretamente pelo magistrado, bem como da ilegalidade da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante. No mérito, requer a absolvição do réu por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, realizando, por fim, considerações sobre a pena, em caso de condenação (fls. 204/223).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Rechaço, de início, a alegação de nulidade decorrente de suposta violação ao artigo 212, do Código de Processo Penal, porquanto a mera inversão da ordem das indagações não gera nulidade, inexistindo prejuízo ao acusado, que estava devidamente assistido pelo Defensor, e poderia refutar ou questionar eventual pergunta inoportuna feita pelo magistrado. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, V e VII; c.c. artigo 14, II do CP) - PRELIMINAR. Nulidade por inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal. Rejeição. MÉRITO - Pleito de impronúncia. Impossibilidade - Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes nas declarações da vítima e depoimento do policial militar - Qualificadoras imputadas que encontram razoável suporte. Exclusão somente quando manifestamente impertinentes - Recurso desprovido, com correção ex officio do dispositivo da sentença para constar a forma tentada do delito. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1503619-75.2018.8.26.0536; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021, g.n.)

Revisão Criminal - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima - Preliminar - Alegada inobservância do disposto no artigo 212 do CPP rechaçada - Mérito - Condenação definitiva bem alicerçada nas provas coligidas - Contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso de lei não verificadas - Tese de participação de menor importância afastada - Reprimenda e regime prisional bem fixados - Pedido de mudança do regime inicial fixado por aplicação do artigo 387 §2º do Código de Processo Penal - Análise pelo Juízo de Execução - Pedido revisional julgado improcedente. (TJSP; Revisão Criminal 0039764-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - Resistência - Recurso da defesa - Preliminar Rejeitada - A nova

redação do artigo 212, do Código de Processo Penal, não suprimiu do juiz a possibilidade de efetuar as suas perguntas para o esclarecimento da verdade real - Ilícitude das provas - Inocorrência - Ausência de comprovação de violência iniciada pelos guardas municipais - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas, tendo em vista os depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais responsáveis pela diligência - Validade - Resistência comprovada - Acusado opôs-se à execução de ato legal - Pena inalterada - Agravante de calamidade pública corretamente reconhecida - Modificado o percentual de elevação da pena na segunda fase da dosagem - Regime prisional estipulado com critério, mercê da presença de maus antecedentes e da reincidência - Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502302-40.2020.8.26.0320; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021, g.n.)

ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Preliminares de nulidade processual. Violação ao art. 212, do CPP. Inocorrência. Defesa que não especificou a efetiva causa da nulidade, nem tampouco o prejuízo suportado pelo réu. Validade do reconhecimento fotográfico efetivado pela vítima. Cautelas recomendadas pelo artigo 226, do CPP, que podem ser dispensadas, especialmente porque, na hipótese, o ofendido ratificou tal reconhecimento em juízo. Mérito. Prova segura da autoria, da materialidade delitiva e das causas de aumento. Depoimento coerente e seguro do investigador de polícia, em consonância com os relatos da vítima e as imagens da câmera de segurança e a confissão do corréu. Negativa do apelante isolada no conjunto probatório. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas acrescidas de um terço pela personalidade voltada à prática de crimes e pela vultosa quantia de dinheiro subtraída e não recuperada. Na segunda fase, suficiente a majoração de um quinto (e não de metade), em razão da reincidência múltipla e específica. Na última fase, penas aumentadas na fração única de trinta e um trinta avos, o que é mais benéfico ao réu do que dois aumentos sucessivos, devendo ser mantida. Concurso formal bem reconhecido, com aplicação da fração de aumento de um sexto, diante da diversidade de patrimônios atingidos (duas vítimas). Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido para a redução das penas, rejeitada a matéria preliminar. (TJSP; Apelação Criminal 0001748-06.2020.8.26.0022; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Amparo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021, g.n.)

De igual modo, não merece guarida a alegação de ilicitude da busca pessoal, podendo e devendo os agentes públicos proceder à averiguação e abordagem de pessoas, segundo critérios de conveniência e oportunidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso concreto, desde que, obviamente, não haja abusos ou excessos passíveis de responsabilização pessoal. Confira-se:

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Preliminares de nulidade - Ilegalidade da busca pessoal - Inocorrência - comportamento suspeito em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e tentativa de fuga ao perceber a aproximação da viatura policial - Circunstâncias a indicar a justa causa para a atuação policial - Posterior apreensão de drogas em poder do acusado, confirmando a legalidade da abordagem - Quebra da cadeia de custódia - Inocorrência - Mero erro de digitação do laudo toxicológico que não comprometeu a prova da materialidade do delito - Preliminares rejeitadas - Mérito - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de porções de 'crack' e de cocaína em poder do acusado - Negativas contraditórias apresentadas pelo réu em ambas as fases da persecução criminal - Consistentes depoimentos dos policiais militares - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Pena-base fixada no mínimo legal a minguada de maus antecedentes - Acréscimo de $\frac{1}{4}$ à pena ante a circunstância agravante da reincidência - Possibilidade de redução para o patamar de $\frac{1}{6}$ - Majoração da pena

em 1/6 ante a causa de aumento correspondente ao tráfico de drogas praticado nas imediações de escola pública - Pena ajustada - Regime inicial fechado mantido - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Rejeitadas as preliminares, recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500831-88.2019.8.26.0557; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020, g.n.)

No mérito, a pretensão punitiva merece acolhimento.

Presente a materialidade do delito, tendo em vista o auto de prisão em flagrantes (fl. 04), o boletim de ocorrência (fls. 09/10), o auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 23/30 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 103/105.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista o depoimento das testemunhas.

O Guarda Municipal MARCO ANTONIO PIMENTEL asseverou que estava em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado, que dispensou algo ao solo. Após abordagem, apreenderam em poder do réu R\$ 16,00 em dinheiro. Na sacola, verificou que existiam 55 (cinquenta e cinco) porções de "crack" e 25 (vinte e cinco) de "cocaína". Indagado, o réu disse que estava vendendo as drogas para conseguir sustentar seu vício. Uma semana antes, o acusado havia sido detido no mesmo local por tráfico.

Em uníssono foi o depoimento do outro guarda, EVERTON VAZ DE OLIVEIRA.

Por fim, o réu, em interrogatório judicial, negou a autoria do delito, aduzindo que é apenas usuário, e que não é proprietário das drogas localizadas, não sabendo de quem eram. Disse, ainda, que não conhece os guardas que efetuaram sua prisão em flagrante. De outro lado, confirmou que havia sido detido nesse local dias antes.

Note-se que o depoimento do réu em juízo restou isolado no conjunto probatório colhido no bojo destes autos.

Cumpramos ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. (grifo nosso)

No caso vertente, o relato dos guardas, a quantidade e variedade de drogas, bem como seu modo de acondicionamento, além da confissão informal, corroboram a tese de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros. Ademais, nos termos da prova oral colhida, o réu havia sido preso no mesmo local, dias antes, comercializando entorpecentes.

Tal informação encontra absoluto amparo na folha de antecedentes e certidões de fls. 39/41, constando que, nos autos do processo nº 1502226-79.2021.8.26.0320, o denunciado fora preso em flagrante aos 18/07/2021, sendo-lhe, porém, concedida a liberdade provisória naquela oportunidade.

Por esse motivo, a despeito da primariedade e dos bons antecedentes, não poderá o acusado ser beneficiado pelo redutor do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois faz do comércio espúrio seu meio de subsistência, o que obsta o reconhecimento da minorante. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. (EResp 1.431.091/SP, Terceira Seção do C. STJ, Rel. Ministro Felix Fischer, de DJe 01/02/2017, g.n.)

Perfeitamente possível, por fim, que o denunciado seja usuário de drogas, mas que comercialize os entorpecentes para conseguir sustentar o próprio vício, não havendo se falar em desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Acerca do tema, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Recurso defensivo - Pretendida absolvição ou desclassificação - Impossibilidade - Materialidade, autoria e destinação das drogas evidenciadas - Palavra dos policiais às quais se empresta relevo probatório - A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita - Condenação mantida - Pena bem dosada - Réu reincidente específico - Confissão não verificada - Exegese da súmula nº 630, do STJ - Minorante inaplicável ante a recidiva - Regime fechado adequado ao caso e bem fundamentado na origem - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500179-76.2019.8.26.0232; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cesário Lange - Vara Única; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado, resistência e conduzir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano. Sentença condenatória. Defesa

requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, bem como a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e indubitosa a condenação. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Inviabilidade de desclassificação para uso próprio. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Crime de resistência caracterizado. Disparo de arma de fogo contra os policiais. Da mesma forma, crime de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano configurado. Dosimetria não merece reparo. Aplicação do redutor mantida à míngua de apelo ministerial. Regime fechado bem fundamentado para o tráfico. Regime semiaberto mantido para os delitos apenados com detenção. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0002419-41.2017.8.26.0537; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019, g.n.)

Imperativa, nesse contexto, a condenação.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são favoráveis, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Malgrado o entendimento perfilhado pelo Ministério Público, não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, uma vez que o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, atinge indistintamente toda a sociedade, podendo, inclusive, ser um dos motivos para o cometimento do crime. Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Impossibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do aumento na pena-base. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para a prática do crime. Agravante prevista artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal. Manutenção. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Súmula nº 630 do STJ. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicção a atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido. Perda do cargo público. Agente penitenciário. Efeito da condenação. Inteligência do artigo 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal. Perdimento de bens e valores. Necessidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501463-64.2020.8.26.0530; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021, g.n.)

Ainda na segunda fase, não incidem atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, afastando-se o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme acima declinado, tornando-se definitiva, por conseguinte, a reprimenda penal em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

O valor do dia-multa deve ser calculado em seu mínimo legal, à míngua de elementos que permitam aferir a situação econômica do acusado.

Considerando-se a quantidade de pena, as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e os bons antecedentes, estabeleço o regime inicial semiaberto para a pena de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do CP.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado ELIEL RODRIGO DA SILVA, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, pela prática de conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Autorizo a incineração da droga apreendida, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como a perda dos bens e valores apreendidos, revertidos ao Funad, com lastro no artigo 63, § 1º, da Lei de Drogas, ressalvados eventuais direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados oportunamente, se o caso.

Tendo sido beneficiado por decisão proferida em sede de HC pelo C. STJ (fls. 180/183), concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada a gratuidade, pois assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA